

1501098-26.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade. Pleiteou o afastamento do privilégio.

A Defesa pediu a absolvição, sustentando ilicitude da ação dos policiais e argumentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado. Subsidiariamente, requereu a aplicação da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501098-26.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2199330/2022

- DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2199330/2022 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ LUIS SANCHES

Réu Preso

Contr. nº 2022/000870

Aos 18 de outubro de 2022, às 13:30 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Antonio Carlos Perez Antunes da Silva foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu ANDRÉ LUIS SANCHES (preso nosso CDP local). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PM JAIR DA SILVA PEREIRA e PM Felipe Carvalho das Dores.

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes - imagem(ns) exibida(s) durante audiência.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Foi dada ciência à Defesa do documento juntado pela acusação (fls. 136/140).

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (PM Jair e PM Felipe) e em seguida o interrogatório do réu foi

captado e gravado em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências. Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). ANDRÉ LUIS SANCHES, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois no dia 22 de julho de 2022, por volta das 21h16, na Rua Silva Jardim, 1600, Cidade Alta, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 33,6g de cocaína em pó, distribuídos em 60 invólucros, substância entorpecente a qual determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 66/69). O réu foi notificado, a denúncia foi recebida e durante a instrução prestaram depoimento as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o réu interrogado. A ação penal deve ser julgada procedente. Primeiramente, não há que se falar em nulidade da busca pessoal, visto que o acusado estava em ponto de tráfico de drogas e demonstrou atitude suspeita mudando de direção ao ver a viatura, sendo, portanto, plenamente justificável a abordagem. A materialidade delitiva foi confirmada nos autos pelo auto de exibição e apreensão a fl. 10, foto a fl. 11 e laudo pericial a fls. 80/82. Da mesma forma, comprovada a autoria delitiva. De fato, o policial Jair relatou, na fase informativa (fls. 03), que "na data e horário dos acontecimentos, estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina quando, defronte ao bar existente no local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, se depararam com o ora indiciado, a quem decidiram abordar para averiguação. Que, realizada a busca pessoal, com o averiguado foram localizadas 10 porções supostamente de cocaína, todas embaladas e prontas para o comércio a terceiros. Que, após breve vistoria, foram localizadas, homiziadas numa árvore próxima, outras 50 porções idênticas às que estavam em poder de André Luis. Que, indagado, o abordado negou a propriedade dos entorpecentes". Em juízo manteve sua versão. Acrescentou que as drogas escondidas estavam do outro lado da rua e que o réu foi abordado porque mudou de direção ao ver a viatura. O policial Felipe corroborou as informações prestadas pelo seu companheiro de farda. Disse que informalmente o réu confessou a prática do tráfico. Vendo a imagem de fls. 11, o policial disse que não sabia se ele estava na posse de porções de cor vermelha, rosa ou mescladas. O réu não indicou onde estavam as drogas. Talvez tenha passado informações erradas ao delegado porque lá constou que o réu não tinha confessado. Assim, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, juntamente com a apreensão de dinheiro, somadas às circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam o comércio ilícito. De fato, o réu estava em ponto de tráfico de drogas, mostrou atitude suspeita e na sua posse foram encontradas 10 porções de drogas e nas proximidades outras 50 e quantia em dinheiro. Neste panorama, devidamente demonstrados os fatos descritos na denúncia. Diante do acima exposto, requer-se a procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da incoativa. Na aplicação da pena há que se observar que o réu não ostenta maus antecedentes criminais (certidão a fls. 76/77), mas responde a outro processo de tráfico, no qual havia sido preso há menos de 20 dias destes fatos, ocorrido no mesmo local, conforme denúncia anexada nesta data - certidão a fls. 76 - evidenciando que se dedica a atividades criminosas e não faz jus à causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Outrossim, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, de acordo com as normas legais, e porque o crime de tráfico merece um grau maior de reprovabilidade, pois causa sérias consequências no meio social, notadamente no meio familiar, fomentando o uso indiscriminado de entorpecentes e, conseqüentemente, a prática de outros crimes pelo usuário, como pequenos furtos e roubos, os quais são praticados com o escopo de sustentar o seu vício. Incabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que reconhecida a impossibilidade de ser aplicado o redutor pelas razões antes mencionadas, a pena suplantará 04 anos, bem como o crime em questão é de elevada gravidade, o que demonstra não ser a medida socialmente adequada. Por fim, uma vez que comprovado

que o dinheiro apreendido era oriundo do comércio de drogas, o Órgão Ministerial requer que seja decretada sua perda.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). ANDRE LUIS SANCHES vem processado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme os fatos narrados na inicial acusatória. Após o recebimento da denúncia, a ação penal teve seu regular trâmite e a instrução foi encerrada na presente audiência. Em suas alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Ocorre, contudo, que a pretensão ministerial não encontra guarida, devendo a ação penal ser julgada improcedente. Com efeito, segundo consta, o acusado foi preso em flagrante após sofrer abordagem dos policiais militares que suspeitaram de sua conduta. Ocorre, porém, que ao explicarem os motivos que os levaram a suspeitar do réu, os militares apenas disseram que ele estava em local conhecido como ponto de tráfico e que apresentou "nervosismo" e mudou o "rumo de direção", o que acarreta a sua ilegalidade. De fato, como cediço, a revista pessoal é medida excepcional que só pode ser justificada diante da existência de fundada razão de que a pessoa abordada esteja em posse de arma proibida, objeto ou papéis que constituam o corpo de delito (art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal). Ou seja, para haver a busca pessoal, deve haver "fundada suspeita" da ocultação de algum objeto ligado ao crime. Mas isso não aconteceu. Na verdade, antes da abordagem, não existia qualquer dado concreto – e objetivamente aferível – de que o réu estaria praticando o crime de tráfico de entorpecente (ou qualquer outro delito). A abordagem dele se deu mediante critério meramente subjetivo, o que não é suficiente para autorizar a busca pessoal, sob pena de violação ao direito constitucional à intimidade (art. 5º, X, CF). Apenas para ilustrar, o Superior Tribunal de Justiça recentemente entendeu como ilegal a busca pessoal efetivada após um suposto "nervosismo" da pessoa abordada, o que pode ser aplicado perfeitamente ao caso em apreço. "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. REVISTA PESSOAL E INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio. 2. Também há a compreensão neste Superior Tribunal de que se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 3. No caso concreto, o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais não indicam a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem, as buscas foram motivadas no "nervosismo" apresentado pelo acusado. Não ficou consignado em sentença nem no acórdão impugnado que os policiais haviam presenciado o paciente vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse a abordagem pessoal. 4. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. (HC 659.689/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). E, como se observa, o entendimento do Tribunal Superior é no sentido que o fato do crime em questão (tráfico de drogas) ser classificado como permanente não importa, pois a suposta infração penal só veio à tona depois de uma abordagem feita a partir de mera conjectura. Trata-se na verdade daquilo que se tem chamado de fishing expedition (pescaria probatória), isto é, os agentes policiais realizam diversas abordagens meramente especulativas – muitas vezes fundadas em estereótipos criminais – com o intuito de encontrar algum objeto ilícito, ensejando assim a prisão da pessoa "suspeita". Não existia, portanto, uma causa provável e o encontro das drogas se deu de maneira absolutamente fortuita. Logo, a conduta dos agentes policiais que realizaram a abordagem/revista pessoal no acusado sem a existência de justa causa deve ser considerada ilegal. E uma vez reconhecida a ilicitude, todos os demais elementos derivados da busca igualmente devem ser

considerados ilegais, o que deve resultar na absolvição do réu, por ausência de provas válidas. Afinal, é evidente o nexó existente entre a revista pessoal e todos os elementos que deram suporte ao início da ação penal. Excluindo-se a busca ilegal, não haveria prisão, oferecimento da denúncia e início da ação penal. Logo, diante do todo exposto, requer-se o reconhecimento da ilicitude da ação policial e a consequente absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal, pela absoluta falta de qualquer prova válida. Caso, no entanto, seja superada a questão sobre a invalidade das provas, a Defesa pugna pela absolvição do acusado em decorrência da fragilidade probatória. Isso porque a prova que o incrimina se resume aos depoimentos dos policiais que o prenderam em flagrante. E nessa condição, evidentemente que seus testemunhos não podem ser considerados como totalmente isentos, pois há uma necessidade de justificarem seus atos. A propósito, em juízo, os policiais apresentaram versão divergente daquilo que relataram na delegacia de polícia, já que o policial Felipe insistiu que o réu teria confessado o crime, contrariando o seu próprio depoimento extrajudicial. Não se quer dizer que eles mentiram e que incriminaram o réu injustamente. Mas apenas que seus depoimentos não possuem a isenção necessária para, por si só, sustentarem uma condenação. Além disso, existindo apenas a prova oral, não se pode dar preferência ao depoimento dos servidores municipais em detrimento do interrogatório do acusado, o qual tem em seu favor a presunção de inocência. Assim, mostrando-se frágil o conjunto probatório, requer-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. De maneira subsidiária, a Defesa pugna pela desclassificação da conduta do acusado para a prevista no art. 28, da Lei de Drogas. De fato, ainda que acolhida integralmente a versão dos milicianos, percebe-se que com o acusado só foram localizadas poucas porções de drogas, situação compatível com a condição de usuário. As demais substâncias foram encontradas nos arredores. Logo, estando em plena via pública, poderiam pertencer a qualquer pessoa. Além disso, não se pode olvidar que em pontos de tráfico também são encontrados usuários, assim como as drogas são obtidas nas mesmas embalagens em que são comercializadas. Assim, a prova da traficância é frágil, motivo pelo qual deve prevalecer a situação mais favorável, que no caso é a desclassificação da conduta do acusado para a prevista no art. 28, da Lei de Drogas. Por fim, caso o entendimento de Vossa Excelência seja pela condenação da pessoa acusada, a Defensoria Pública pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, posto que não houve apreensão de quantidade expressiva de substância entorpecente. Já na terceira etapa, requer-se a aplicação da causa redutora de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que não há provas de que o réu é integrante de organização ou associação criminosa, o que fica demonstrado pela ínfima quantidade de droga apreendida. Além disso, trata-se de pessoa absolutamente primária, sem qualquer envolvimento com ato ilícito, nem mesmo na Vara da Infância e Juventude. E, respeitado o entendimento do d. representante do MP, é fato que a jurisprudência dos tribunais superiores tem rechaçada a utilização de processos ou inquéritos em andamento para agravar a pena da pessoa acusada: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PROCEDIMENTOS E/OU PROCESSOS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA APLICAR A MINORANTE FUNDAMENTADAMENTE E RECALCULAR A DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em "investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional" (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. II - A escolha do patamar de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não prescinde de adequada fundamentação. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento" (STF - HC 144309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 26-11-2018 PUBLIC 27-11-2018). Assim, a pena deve ser reduzida no patamar máximo, fixando-se, por consequência o regime inicial aberto. Presentes os requisitos legais, deve ainda a pena privativa de liberdade ser substituída por

restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal. Se este não for o entendimento de Vossa Excelência, requer-se, ao menos, seja fixado o regime inicial semiaberto, o que é compatível com a condição de primário do acusado. Não mais subsistindo os requisitos da prisão preventiva, requer-se que seja deferido ao acusado o direito de recorrer em liberdade, se assim desejar.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

ANDRÉ LUIS SANCHES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de julho de 2022, por volta das 21h16, na Rua Silva Jardim nº 1600, Cidade Alta, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 33,6g de cocaína em pó, distribuídos em 60 invólucros, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia que policiais militares estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de narcotráfico, ocasião em que visualizaram o acusado e o abordaram. Em buscas pessoais, localizaram e apreenderam 10 porções de cocaína. Em seguida, realizaram diligências no local e localizaram outras 50 porções da mesma droga, escondidas em uma árvore existente no local.

Conclui a denúncia que todas as drogas pertenciam ao réu e se destinavam à mercancia ilícita.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 88). Defesa preliminar apresentada às fls. 91/97. Após, a denúncia foi recebida (fl. 106) e o réu foi citado (fls. 133).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade. Pleiteou o afastamento do privilégio.

A Defesa pediu a absolvição, sustentando ilicitude da ação dos policiais e argumentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal com o reconhecimento do privilégio.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

Autoria e materialidade do delito estão comprovadas pelos seguintes elementos:

- 1) boletim de ocorrência de fls. 07/09;
- 2) auto de exibição e apreensão de fls. 10 e fotografias de fls. 11;
- 3) laudo de constatação de fls. 13/15 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 80/82, ambos com resultados positivos para cocaína em relação às substâncias apreendidas;
- 4) prova oral, que, a seguir, será analisada.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 04), o réu negou o tráfico. Declarou que estava apenas com uma porção de drogas quando foi abordado e que o restante "foi forjado" pelos policiais.

Interrogado em juízo (gravação), disse que, no dia dos fatos, saiu do serviço e parou no bar, distante um quarteirão de sua casa. Ali tomou duas cervejas. Saiu e estava descendo em direção à sua casa. Neste momento, foi abordado por policiais, os quais encontraram em seu poder um pino de cocaína e R\$ 60,00. O dinheiro era fruto de seu trabalho de pintor. Desconhece as demais drogas. Não as viu onde foram encontradas. Alguns dias antes dos fatos, foi abordado por outros policiais nas proximidades com porção de maconha e também foi preso por tráfico de drogas, mas foi solto na audiência de custódia.

A versão do réu foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase extrajudicial (fls. 03) e em juízo (gravação), o policial militar Jair da Silva Pereira declarou que na data dos fatos estava em

patrulhamento de rotina com seu parceiro de farda, quando, na frente de um bar, local conhecido pelo tráfico de drogas, depararam-se com o acusado e decidiram abordá-lo para averiguação, pois ele agiu de forma suspeita ao notar a aproximação da viatura, mostrando nervosismo, abaixando a cabeça e mudando imediatamente de direção. Realizada busca pessoal, encontraram com ele 10 porções de cocaína, todas embaladas individualmente, além de dinheiro. Após breve vistoria nas imediações do local dos fatos, encontraram outras 50 porções de cocaína embaladas de forma idêntica às que estavam na posse do acusado, as quais estavam escondidas em uma árvore, do outro lado da rua. Disse que, do local onde estava, o réu conseguia exercer vigilância sobre o local onde as drogas estavam escondidas. Por fim, afirmou que não conhecia o acusado anteriormente e disse não se lembrar qual foi a alegação dele no momento dos fatos.

No mesmo sentido as declarações prestadas na delegacia de polícia (fls. 04) e em juízo (gravação) pelo policial militar Felipe Carvalho das Dores, o qual, entretanto, sob o crivo do contraditório, acrescentou que, informalmente, assim que abordado, o réu admitiu que estava realizando tráfico de drogas no local dos fatos. Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a

credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido.” (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO – j. 11/09/2020) – g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS – j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR – j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO – j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR – j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos agentes da polícia: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos policiais não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que, no dia e local dos fatos, o réu trazia consigo e guardava 60 invólucros de “crack”, os quais eram destinados ao comércio e consumo de terceiros, substância esta que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De fato, o réu foi surpreendido pelos policiais militares em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e agiu de forma suspeita ao notar a aproximação da polícia, demonstrando nervosismo, abaixando a cabeça, tentando se esquivar da abordagem e saindo em direção oposta, o que ensejou a abordagem policial, que foi lícita (isso afasta a tese defensiva de ilicitude e nulidade), pois havia evidente situação indicativa de possível crime de tráfico de drogas por ele.

Em revista pessoal, encontraram em posse do acusado 10 invólucros de cocaína, embalados individualmente em pequenas porções, na forma como comumente são comercializadas. Nas imediações do local encontraram mais 50 porções, idênticas às que estavam em poder do acusado, ocultas em uma árvore, as quais evidentemente lhe pertenciam e eram igualmente destinadas ao comércio ilegal, pois não havia qualquer outro suspeito nas proximidades e, do local onde estava, ele conseguia exercer vigilância sobre o esconderijo dos entorpecentes.

Inconteste, dessa forma, que as drogas apreendidas pertenciam ao réu e eram destinadas ao comércio, destino este que se reforça diante da quantidade incompatível com a situação de mero usuário.

Outrossim, ele possuía quantia em dinheiro (R\$ 60,00), cuja origem lícita não foi comprovada.

Ademais, ainda que se considerasse a possibilidade de o acusado ser usuário de drogas, a condição de usuário não é inconciliável com a traficância, pois não é incomum usuários traficarem para sustentarem o próprio vício e ainda obterem algum lucro.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o

principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não esbanja a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO." (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

"MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

Não obstante responda a outro processo por tráfico de drogas, o réu deve ser considerado primário e de bons antecedentes, pois ainda não sofreu condenação criminal definitiva por outros crimes (certidão de fls. 30/31).

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis. A quantidade de drogas apreendidas, embora significativa a ponto de indicar o tráfico, não fugiu à normalidade da espécie.

Assim, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Inexistem agravantes.

Eventuais atenuantes não autorizam a redução das penas aquém do mínimo legal.

Não há causas de aumento de pena.

Não havendo comprovação da ocorrência de algum dos impeditivos do privilégio elencados no parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06 (em razão do princípio da presunção de inocência, a existência de processo em andamento não permite a

afirmação de que ele tem feito do crime seu meio de vida. Ademais, nos v. acórdãos proferidos nos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e n. 1.977.180/PR, processos-paradigma do Tema n. 1139 - Tráfico - Privilegiado - Inquéritos - Ações - Penais - Andamento, o C. STJ fixou a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06), possível a aplicação do redutor de que trata essa norma.

Assim, reduzo as penas em 2/3, perfazendo um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

Necessária a fixação do regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena, em razão da maior gravidade da conduta do acusado e de sua grande ousadia ao praticar o crime em comento em pleno gozo de liberdade provisória, a qual obteve dezesseis dias antes dos fatos em questão, ocasião em que foi preso em flagrante pela mesma prática delitiva no mesmo local dos fatos (cf. certidão de fls. 30, proc. 1501003-93.2022 da 3ª Vara Criminal local, encontrando-se em andamento, e fls. 137/140).

Ainda que eventualmente não sofra condenação criminal definitiva naquele feito, o fato de praticar crime em pleno gozo de liberdade provisória indica tratar-se de pessoa que não se intimida com a ação do Estado, que não valoriza os benefícios que a Justiça lhe concede e que, portanto, requer tratamento mais firme para que a pena cumpra as funções de prevenção e reprovação dos crimes.

Acrescente-se a tais fundamentos as graves consequências do crime em questão, que fomenta a prática de vários outros delitos, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que dificilmente conseguem se livrar do vício.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou a concessão de "sursis", bem assim o direito de recorrer em liberdade, sendo necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas ou da suspensão da pena, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seu grave ato.

Registro que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o tempo de prisão provisória do réu não é suficiente para progressão de regime.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia CONDENO o réu ANDRÉ LUIS SANCHES a cumprir um ano e oito meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado que a quantia apreendida em poder do acusado junto com as drogas (R\$ 60,00), cuja origem não foi comprovada, é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Conforme exposto acima, o acusado respondia a outro processo pela prática de crime idêntico ocorrido há dezesseis dias dos fatos em questão, e, inclusive, gozava do benefício de liberdade provisória naquele feito quando praticou o crime em questão. Assim, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual é necessária para garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa e fica, assim, mantida.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra preso, servindo-se a presente de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo Representante do MP, RÉU e DEFESA foi dito que NÃO DESEJA(M) RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se o necessário. Oportunamente, archive-se.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.